

次の【事例】に関する後記アからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。

【事 例】

甲は、友人乙から、借金の返済に窮している旨の相談をされ、乙に対し、「実家に親父の高級腕時計がある。それを盗んで売りさばけば金になる。」と提案し、甲と別居する甲の実父V方からV所有の腕時計を盗むことを唆した。乙は、甲の提案を受け、V方に窃盗に入ることとしたが、仮に、窃盗を行う際にVらに見付かって逮捕されそうになった場合には、Vらをナイフで脅してこれを抑圧し、逃走しようと考えた。

乙は、某日午後0時頃、前記の意図でナイフを購入し、それを携帯してV方に向かい、同日午後1時頃、腕時計を盗む目的で、V方に窓から侵入した上、寝室でV所有の腕時計（時価100万円相当）を窃取した。乙は、その後間もなく、V方玄関ドアの施錠を外して戸外に出て、誰からも発見、追跡されることなく、V方から約1キロメートル離れた公園まで逃げた。乙は、同所において、やはり現金も欲しいと考え、再度V方に窃盗に入ることを決意し、V方に戻り、同日午後1時30分頃、V方玄関内に入ったところ、その直後に帰宅してきたVと鉢合わせとなったことから、逮捕を免れるため、前記ナイフをVの面前に示し、Vが恐怖の余り身動きできないうちに逃走した。

乙は、翌日、甲に前記腕時計の売却を依頼した。甲は、同腕時計の売却先を探し、知人丙に対し、その買取りを申し向けたところ、丙が80万円で購入する旨答えたことから、同腕時計を丙に売却した。甲は、丙から同腕時計の売却代金として80万円を受け取ったが、その後、これを自己のものにしようと考え、乙に無断で、その全額を遊興費として費消した。

【記 述】

ア. 乙が某日午後0時頃に購入したナイフを携帯してV方に向かったことについては、「強盗の罪を犯す目的」が認められないので、乙に強盗予備罪は成立しない。

イ. 乙がVをナイフで脅迫したことについては、腕時計の窃取行為との時間的・場所的な近接性に照らせば、窃盗の機会の継続中に行われたものといえるため、乙に事後強盗罪が成立する。

ウ. 甲が乙に腕時計の窃盗を唆したことと、その売却をあっせんしたことは、原因と結果の関係に立つので、窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪は牽連犯となる。

エ. Vの直系血族である甲には盗品等に関する罪について親族等の間の犯罪に関する特例が適用されるため、盗品等有償処分あっせん罪について、甲はその刑を免除される。

オ. 甲が腕時計の売却代金を費消したことについては、同腕時計の窃盗犯人である乙は甲に対してその代金の引渡しを請求する権利がないので、甲に委託物横領罪は成立しない。

1. 1個 2. 2個 3. 3個 4. 4個 5. 5個

No438

犯罪の成否

正答率

共通R 1-20

正解

5

55%

ア 誤っている

本事例では、乙に「強盗の罪を犯す目的」(237条)が認められるかが問題となる。最決昭54.11.19(百選Ⅱ「第7版」43事件)は、「刑法237条にいう『強盗ノ目的』には、同法238条に規定する準強盗を目的とする場合を含む」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、238条が事後強盗につき「強盗として論ずる」と規定していること、居直り強盗と事後強盗との差は紙一重であるということを挙げている。そして、事後強盗の予備罪は、窃盗に着手後発見されたら、逃走の際に暴行・脅迫を行うとの意図で凶器を携帯する場合に成立する。本事例では、乙は、窃盗を行う際にVらに見付かって逮捕されそうになった場合には、Vらを脅してこれを抑圧し、逃走しようという意図でナイフを購入し、それを携帯してV方に向かっていて、したがって、本事例の乙に事後強盗罪の予備罪としての強盗予備罪が成立する。

イ 誤っている

本事例では、乙のVに対する脅迫が窃盗の機会の継続中に行われたといえるかが問題となる。最判平16.12.10(百選Ⅱ43事件)は、被害者方で財物を窃取した犯人が、だれからも発見、追跡されることなく、いったん同所から約1キロメートル離れた場所まで移動し、窃取の約30分後に再度窃盗をする目的で被害者方に戻った際に逮捕を免れるため家人を脅迫した事案において、「上記脅迫が、窃盗の機会の継続中に行われたものということとはできない」としている。その理由として、判例は、「被告人は、財布等を窃取した後、だれからも発見、追跡されることなく、いったん犯行現場を離れ、ある程度の時間を過ごしており、この間に、被告人が被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況はなくなった」ということを挙げている。本事例は、判例の事案と同様に、Vに対する脅迫は窃盗の機会の継続中に行われたとはいえない。したがって、本事例の乙に事後強盗罪は成立しない。

ウ 誤っている

本事例では、窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪の罪数処理が問題となる。最判昭24.7.30は、「他人に対し窃盗を教唆し且つその赃物(注:盗品等)の売却を周旋して牙保(注:有償処分のあっせん)をしたときでも、それは窃盗教唆と赃物牙保の二罪が成立するのであつて後者が前者に吸収さるべきものではない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、窃盗の教唆と盗品等に関する罪との間に類型性が認められる場合のあることは否定し難いが、構成要件的に定型的な類型があるとまでは言い難いということを挙げている。よって、本事例の甲に窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪が成立し、両罪は併合罪となる。

エ 誤っている

本事例では、257条1項が適用されるためには、誰と誰の間に親族関係が必要かが問題となる。最決昭38.11.8は、「刑法257条1項は、本犯と赃物(注:盗品等)に関する犯人との間に同条項所定の関係がある場合に、赃物に関する犯人の刑を免除する旨を規定したものである」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、親族間では、情においてこの種の犯罪を犯しがちであり、あながちそれを否定し難いということを挙げている。本事例では、本犯である乙と盗品等に関する犯人である甲との間に親族関係は認められない。したがって、本事例の甲に盗品等に関する罪について親族等の間の犯罪に関する特例は適用されず、その刑が免除されることはない。

オ 誤っている

本事例では、盗品等を処分するよう委託された者が売却代金を領得した場合に委託物横領罪が成立するか否かが問題となる。最判昭 36.10.10 は、盗品等の有償処分のあっせんをした者がその売却代金を着服した事案において、「刑法 252 条 1 項の横領罪の目的物は、単に犯人の占有する他人の物であることを以つて足るのであつて、その物の給付者において、民法上犯人に対しその返還を請求し得べきものであることを要件としない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、まず、「他人の物」の要件との関係で、委託された行為に基づいて取得した金銭の所有権は委託者にあるとされていること及び民法上の所有権と刑法上の所有権を同義に解する必然性はなく、刑法独自の観点から給付者に所有権を認めてよいということを挙げ、次に、委託信任関係の要件との関係で、窃盗犯人とはいえ他人からの委託信任関係は保護すべきであるということを挙げている。本事例では、腕時計の売却代金は、甲が窃盗犯人である乙から依頼を受けた売却行為に基づいて取得した金銭である。同金銭が不法な原因により発生したものであったとしても刑法独自の観点から、委託者である乙に所有権が認められる。そして、窃盗犯人である乙からの委託信任関係も保護すべきである。したがって、本事例の甲に委託物横領罪が成立する。

以上により、誤っている記述は、ア、イ、ウ、エ、オの 5 つであり、したがって、正解は肢 5 となる。

